

1500612-43.2020.8.26.0621
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/04/2022
... exordial.

A propósito:

"Apelação - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória - Preliminar afastada - Emendatio Libelli - Possibilidade - Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal - Mérito - Pretensão à absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1500612-43.2020.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500612-43.2020.8.26.0621
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2194087/2020 - 2º Distrito Policial de Lorena, 12876024 - 2º Distrito Policial de Lorena, 1012/20/204 - 2º Distrito Policial de Lorena
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
JOAO MOTA NETO e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOÃO MOTA NETO, qualificado nos autos, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da inicial acusatória de fls. 89/90.

Oferecida a denúncia, o réu apresentou a sua defesa prévia (fls. 115/358). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 07/10/2020, com designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 359/361).

Durante a instrução criminal realizou-se a inquirição das testemunhas, sendo o réu

interrogado ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, na forma de memoriais escritos.

O Ministério Público pugnou, preliminarmente, pela adequação da capitulação dos fatos na denúncia, e no mérito, pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado, pela prática do delito de tráfico de drogas, com o reconhecimento da agravante disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei, ora em voga (fls. 489/498).

Já a douta defesa requereu a improcedência da ação penal, por insuficiência de provas. Alegou, ainda, que a conduta praticada é atípica, por ter o acusado agido culposamente; ou, mediante coação, o que afastaria sua culpabilidade. Com relação à causa de aumento do artigo 40, da mesma Lei, requereu o seu afastamento, à míngua de comprovação da sua existência. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena mínima; o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de diminuição; o estabelecimento do regime menos severo; e a possibilidade do apelo em liberdade (fls. 503/526).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, razão assiste ao Ministério Público quanto à capitulação descrita na exordial acusatória.

Como se sabe, é permitido ao julgador, à luz do artigo 383, do Código de Processo Penal, dar aos fatos descritos na peça vestibular acusatória definição jurídica diversa da que desta consta, mesmo que em consequência tenha que aplicar pena mais grave, como no caso.

E assim o é porque o réu não se defende da capitulação atribuída, mas sim, dos próprios fatos descritos na denúncia. É a chamada *emendatio libelli*, a qual permite a este Magistrado proceder a correção da inicial, resultando tão somente no necessário ajuste dos fatos narrados à correta tipificação.

Registre-se que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, já que as derradeiras alegações defensivas foram apresentadas após a manifestação ministerial; e, ainda que assim não tivesse ocorrido, encontra-se baseado em fatos devidamente narrados na peça inaugural desta ação penal, ou seja, antes da notificação e citação do acusado.

Portanto, como a denúncia descreve que o réu, “em concurso com o inimputável ‘J.P.R.A.’, traziam consigo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 247 invólucros plásticos contendo cocaína”, certo é que essa conduta está tipificada no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e não no artigo 35, dessa lei, como constou originalmente da exordial.

A propósito:

“Apelação – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Preliminar afastada – *Emendatio Libelli* – Possibilidade – Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal – Mérito – Pretensão à absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Palavra de agentes policiais – Credibilidade – Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado – Sentença mantida – Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 0012710-14.2014.8.26.0438; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)
(Ênfase minha).

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos laudos de constatação provisória (fls. 26/28) e toxicológico definitivo (fls. 80/82), os quais atestaram a presença de "cocaína", substância presente na lista, da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; bem como as provas orais existentes nos autos.

A prova de autoria é igualmente certa, recaindo sobre a figura do acusado. Senão vejamos.

O policial militar Marcelo Rodrigues da Silva confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse que o réu, após o encontro dos entorpecentes ao seu veículo, primeiramente, negou que deles soubesse, dizendo que apenas prestava o serviço de "Uber" (transporte pago por meio de aplicativo). Contudo, logo após, acabou confessando que aquela era a quarta vez que transportava drogas para o "Morro do Querosene". De acordo com o depoente, o acusado lhe contou que recebia R\$ 30,00 (trinta reais) por "corrida", enquanto o menor que era transportado por ele, disse que a droga era de propriedade de "Breno Capela". Esclareceu que não conhecia o réu até aquele dia. Questionada, a testemunha afirmou que o réu demonstrou surpresa com a abordagem policial, mas não com a localização dos entorpecentes dentro do seu veículo.

Em sentido semelhante depôs seu companheiro de farda, André Luiz de Jesus da Silva. Referido policial acrescentou que a Polícia Militar já havia recebido informações de que o veículo em questão vinha sendo utilizado no transporte de entorpecentes, embora não conhecesse o acusado até a data dos fatos. Indagado, disse que o adolescente J.P.R.A admitiu no momento do flagrante que João Mota sabia da existência dos entorpecentes, apesar de esclarecer em que momento tal ocorreu. O agente da lei também disse que o menor afirmou que os narcóticos eram de "Breno Capela", e que os levariam para Piquete/SP.

A testemunha de defesa Marco Antonio Freire Ayrosa disse que não presenciou os fatos. Contou que durante o tempo em que o réu trabalhou com ele - entre 2011 a 2018 - sempre foi assíduo e bom empregado. Por fim, contou que o acusado voltou a trabalhar com eles, na função de motorista, após ser solto por este processo, e passar por exames de admissão, inclusive toxicológico, sem nenhum apontamento negativo.

Assim como a testemunha anterior, Valéria de Fátima Bueno Guimarães, também arrolada pela defesa, esclareceu que não estava presente quando os fatos ocorreram. Afirmou que já recorreu ao serviço de transporte pago por aplicativo realizado pelo acusado, em uma ocasião.

Nesse mesmo diapasão, depôs a outra testemunha de defesa, Célia Maria Dias Motta.

Por sua vez, o réu negou o delito em seu interrogatório. Disse que na data dos fatos recebeu um pedido de "viagem" pelo aplicativo, de uma pessoa chamada Breno, passageiro que já havia conhecido naquela semana, após realizar "umas duas ou três corridas" (sic). Afirmou que Breno embarcou no bairro Parque das Rodovias, com destino ao bairro Ponte Nova, sendo que no meio do caminho solicitou uma outra "corrida" até a cidade de Piquete/SP, para outra pessoa. Breno desceu em seu destino (Ponte Nova), e já no local de seu desembarque, entrou o adolescente em seu carro, na posse de uma sacola plástica transparente. Interrogado em 24.02.2021 (p. 441/443), João Mota disse ter observado que no interior da sacola havia entorpecentes. Todavia, em seu interrogatório, o réu voltou atrás parcialmente, dizendo que, na verdade, naquela ocasião, apenas questionou o jovem sobre o

conteúdo da sacola, quando então aquele afirmou tratar-se de narcóticos. Afirmou que ao saber disso, se negou a prestar o serviço, iniciando-se uma discussão entre os dois, já que o menor sentado no interior do automóvel, e Breno do lado de fora. Em seguida, mais uma contradição. Na primeira vez em que interrogado, João Mota contou que, nesse exato momento, Breno saiu correndo, em razão da chegada de policiais militares naquele local. Porém, em seu reinterrogatório, o acusado disse que estava dentro do veículo quando visualizou uma viatura policial aproximando-se, momento em que saiu do carro. Disse ter sentido alívio com a situação, por não saber se Breno e o inimputável estavam armados. Indagado, negou que tivesse admitido aos policiais que aquela seria a quarta vez que transportava pessoas com drogas, mas sim, que era a quarta vez que prestava serviços a Breno, esclarecendo desconhecer se este havia transportado entorpecentes em tais ocasiões. Disse que falou aos policiais que receberia R\$ 30,00 pela "corrida" até Piquete/SP, embora nada tenha dito sobre as drogas, até por desconhecer que o menor as transportava. Afirmou que tanto J.P.R.A como Breno lhe coagiram para transporta-los. Disse que nunca havia feito "corrida" até Piquete/SP até então. Ao cabo de sua autodefesa, disse que o carro estava desligado quando os policiais chegaram ao local.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, dúvidas não há de que o réu tinha pleno conhecimento dos entorpecentes na posse do adolescente, decidindo transporta-los, por vontade própria. Afinal, o que se tem no processo é a palavra do réu contra os dizeres dos policiais militares.

Sobre os depoimentos dos policiais militares, nunca é demais lembrar a credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública em minhas decisões, em linha, aliás, com a jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.P.R.A. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Frise-se que os policiais militares envolvidos nesse caso desconheciam o réu até o dia dos fatos.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, como no caso destes autos; afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisor o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão

Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, fixada tais diretrizes, observo que o caso, ora em apreço, é mais um dentre tantos no qual o réu tenta em vão desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova de sua versão em sentido contrário.

Não há como encampar o sustentado pela defesa técnica de que os policiais teriam compreendido equivocadamente as declarações do acusado, que teria tentado dizer que, na verdade, aquela (dia dos fatos) seria a quarta vez que prestava serviço de transporte particular a Breno, nada sabendo se este levava ou não, drogas consigo em tais ocasiões. Afinal, além da experiência dos policiais militares envolvidos nessa ocorrência, segundo a versão destes, inicialmente, o réu negou que soubesse da existência dos narcóticos, apenas admitindo tal fato posteriormente, versão a afastar totalmente a linha de defesa.

Outrossim, inviável acolher a versão exculpatória invocada pelo acusado em seus interrogatórios de uma coação moral irresistível sofrida pelo adolescente Juan e Breno para transportar as drogas apreendidas.

Decerto, conforme os agentes da lei disseram na cerimônia judicial, o veículo em questão, de propriedade de João Mota, já era alvo anterior de suspeitas de ligação com o narcotráfico, por conta de sua utilização no transporte de narcóticos há algum tempo. Além disso, os mesmos policiais igualmente afirmaram que o réu lhes confessou informalmente tal agir, dizendo que aquela não era a primeira vez que assim o fazia.

A bem da verdade é que a própria postura do réu ao se deparar com os policiais militares enfraquece tal versão. Afinal, a conduta do homem médio, alvo de uma coação nos moldes alegados pelo acusado, seria contar imediatamente aos policiais sobre as drogas e a ameaça em andamento, de modo a libertar-se da terrível situação vivenciada, comportamento não adotado por João Mota, segundo os próprios agentes públicos disseram.

Não se discute aqui que o acusado trabalhava à época como motorista de um famoso aplicativo, conforme amplamente demonstrado pelas testemunhas de defesa, bem como pelos documentos juntados aos autos pela sua aguerrida defensora (fls. 128/242 e 243/276). Porém, tal circunstância não o impediria de praticar a conduta criminosa, ora reconhecida, tal como a fundamentação acima exposta.

Além disso, malgrado não tenha sido ouvido em juízo, impende dizer que, em sede policial, o adolescente J.P.R.A, contrariando a praxe no meio infracional/criminoso, onde os inimputáveis costumam "assumir" a responsabilidade por fatos ilícitos praticados por maiores, por estarem sujeito a regime jurídico muito menos rigoroso, indicou que o réu possuía conhecimento das drogas, em linha com a narrativa dos policiais ao longo de toda persecução penal (fls. 14).

Saliente-se não ser defeso a este Julgador utilizar elementos informativos produzidos no curso de inquérito policial, desde que corroborados com provas produzidas sob o crivo do contraditório, como no caso, ora em apreço, por força do já invocado princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

“APELAÇÃO – (...) – Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o adolescente – Alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Elementos informativos que, quando corroborados por provas produzidas sob as garantias do contraditório, podem constituir a formação da convicção do julgador – Precedentes – Referida norma

processual que somente veda a utilização exclusiva dos elementos de informação para justificar a condenação, o que não é o caso dos autos – (...) – Apelação não provida”. (TJSP; Apelação Cível 0001078-47.2018.8.26.0180; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020); e

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO APOIADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do agravante se lastreou em provas produzidas em juízo, notadamente a versão apresentada por uma das vítimas, corroboradas por elementos colhidos na fase policial, não havendo nulidade a ser reconhecida. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ; AgRg no HC 378640/SP; Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro; Órgão julgador: Sexta Turma; Data da publicação: 01/10/2018) (Grifamos).

No mais, pontuo ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia. Basta apenas a prática de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, como no caso “transportar”, esclarecendo-se que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos autos, à luz da quantidade de entorpecente, além das outras nuances acima declinadas.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Também não dúvida alguma sobre o envolvimento do adolescente J.P.R.A, tal como indicou a prova oral, configurando, assim, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Portanto, o caso é mesmo de condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, conforme documentos de fls. 372/373 (folha de antecedentes) e fl. 404 (certidão criminal).

Contudo, insta salientar que a expressiva quantidade de drogas apreendidas (173,68 gramas de 'cocaína', distribuídas em 247 pinos plásticos, do tipo eppendorf), indica que a conduta censurada produziu maior risco ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, a demonstrar reprovabilidade superior à normal.

Além disso, não se pode ignorar que os entorpecentes eram transportados entre duas cidades, com utilização de rodovia federal, inclusive (BR-459), o que também deve ser valorado negativamente.

Logo, considerando as circunstâncias acima, fixo a basilar em 1/5 (um quinto) acima do piso legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na fase intermediária, não há circunstâncias a serem consideradas.

Na terceira etapa, conforme fundamentado anteriormente, incide a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando-a ao patamar de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Por outro lado, igualmente reconheço em favor de João Mota, a redutora disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu primário, sem antecedentes, e à míngua de prova minimamente segura de que este integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades dessa natureza.

A conduta delituosa do acusado, típica de “mula” - pessoa responsável por transportar a droga para terceiro, mediante pagamento - permite a aplicação desse redutor, quando não comprovado nos autos que a participação do réu se deu de forma permanente ou com intuito de associação criminosa para esse fim.

A propósito, o posicionamento recente do TJSP:

“Tráfico de drogas - Provas suficientes para a condenação, que sequer foi impugnada - Reconhecido o tráfico privilegiado - Requisitos legais preenchidos - A ré atuou na condição de “mula”, o que não impede o privilégio - Precedentes dos Tribunais Superiores - Cabível o regime aberto, face à primariedade e à quantidade de pena imposta - Sanção reclusiva substituída por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa”. (TJSP; Apelação Criminal 1501047-08.2019.8.26.0603; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022) (Sublinhado meu).

Mesmo entendimento dos Tribunais Superiores (STF. 1ª Turma. HC 124107, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 04/11/2014; STF. 2ª Turma. HC 131795, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/05/2016; STJ. 5ª Turma. HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 6/4/2017 (Info 602); STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1052075/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/06/2017).

Logo, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), considerando seu passado irretocável até aqui, finalizando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, ausentes outras causas modificadoras.

Malgrado posição pessoal em sentido contrário deste Magistrado, certo é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a figura do tráfico privilegiado, não mais ostenta natureza hedionda, razão pela qual curvo-me a tal posição, prestigiando, assim, a uniformidade das decisões judiciais, corolário do Princípio da Segurança Jurídica.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO, TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. (...) 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico

ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça." (STJ, Recurso Repetitivo, Tema 600, Pet 11796/DF, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/11/2016).

Assim, fixada tal diretriz, em consonância com o quanto disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Por fim, estabeleço o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOÃO MOTA NETO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, diária mínima.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas indicam que a aplicação de medidas despenalizadoras não seriam suficientes para atender aos fins da pena.

Lado outro, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão do regime aplicado.

Custas pelo vencido.

A propósito:

"APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - (...) Impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não caracterizada no caso em comento, uma vez que os apelantes possuem advogados constituídos nos autos - RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1502659-13.2021.8.26.0408; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (Ênfase minha).

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida (R\$89,00), do veículo (Renault/Logan EXPR 10, de cor prata, placas PZK8641), e do aparelho celular (motorola), às fls. 12/13, em favor da União, ante as evidências de serem originários do vil comércio e terem sido utilizados para a prática do crime de tráfico, respectivamente, conforme acima exaustivamente fundamentado, com fulcro no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Caso o aparelho celular não apresente mais conteúdo econômico, após a devida certificação nos autos, fica autorizada sua destruição, observadas as disposições normativas pertinentes. Expeça-se o necessário, com o trânsito em julgado.

Registro que o veículo, embora ainda registrado em nome de terceiro, é de propriedade do acusado, conforme documentos de fls. 289/291.

Anote-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu em recurso extraordinário, com repercussão geral, o Tema 647, que o perdimento do bem, como no caso destes autos, do veículo e do celular, não é necessária a habitualidade na atividade ilícita, logo, como restou cabalmente comprovado que o réu se utilizou desse automóvel para transportar a droga e do celular para se comunicar com o traficante que o contratou para o transporte ilícito, frise-se, ainda que, somente nesta ocasião, é o caso do

seu perdimento.

Veja-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento." (STF; RE 638491; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. Luiz Fux; Julgamento: 17/05/2017; Publicação: 23/08/2017);

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelos defensivos – Inconformismo que se limita ao capítulo da sentença que decretou o perdimento do automóvel e dos telefones celulares apreendidos – Pretensão de cassação desse decreto sob os argumentos de que ele não se aplica ao tráfico privilegiado, os bens têm origem lícita e não há habitualidade no uso deles para a prática de tráfico de drogas – Caso em que esse uso está bem demonstrado – Exigência de habitualidade que é questão controversa no STJ, de modo que não há razão para abandono do entendimento adotado pela Câmara em sede de embargos infringentes: "O fato do carro, eventualmente, possuir origem lícita ou estar registrado em nome de terceiro estranho ao delito, por si só, não obsta a decretação de seu perdimento – Precedentes do STF" – (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1506190-65.2021.8.26.0228; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021); e

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Grifos meus).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para cumprimento do disposto no artigo 71, § 2º do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA